

GUIA ORIENTATIVO

Cookies e proteção de dados pessoais

OUT / 2022



GUIA ORIENTATIVO

Cookies e proteção de dados pessoais

Alexandra Krastins Lopes
Andressa Girotto Vargas
Davi Téofilo Nunes de Oliveira
Isabela Maiolino
Jeferson Dias Barbosa
Lucas Borges de Carvalho
Marcelo Santiago Guedes
Thiago Moraes

Brasília, DF
2022

Presidente Jair Messias Bolsonaro

Diretor-Presidente Waldemar Gonçalves Ortunho Junior

Diretores Arthur Pereira Sabbat
Joacil Basilio Rael
Miriam Wimmer
Nairane Farias Rabelo Leitão

Equipe de elaboração Alexandra Krastins Lopes
Andressa Girotto Vargas
Davi Téofilo Nunes de Oliveira
Isabela Maiolino
Jeferson Dias Barbosa
Lucas Borges de Carvalho
Marcelo Santiago Guedes
Thiago Moraes

Projeto gráfico e editoração André Scofano

Versão 1.0
Publicação digital (outubro / 2022)

ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados
SCN, Qd. 6, Conj. A,
Ed. Venâncio 3000, Bl. A, 9º andar
Brasília, DF · Brasil · 70716-900
www.anpd.gov.br

Sumário

05 Apresentação

08 Conceito e classificações
- 08 O que são cookies?
- 09 Categorias de cookies

13 Cookies e a LGPD
- 13 Aspectos Gerais
- 17 Hipóteses Legais

28 Políticas de cookies

30 Banners de cookies
- 30 O que observar na elaboração
- 33 O que evitar na elaboração de banners de cookies
- 34 Exemplos de banners de cookies

37 Considerações finais

38 Notas

Apresentação

Diariamente, ao ingressar em uma página na internet, somos avisados de que o *site* em questão utiliza cookies. Por isso, é necessário aceitar, recusar ou gerenciar preferências – neste último caso, indicando, de forma mais específica, quais categorias de *cookies* e respectivas finalidades poderão ser utilizadas pelo provedor do serviço. Os *cookies* desempenham atualmente um papel importante na Internet, aprimorando, em alguns casos, a experiência dos usuários e sustentando determinados modelos de negócios. Dentre outras finalidades, os *cookies* viabilizam o funcionamento de páginas eletrônicas e a prestação de serviços na internet, incluindo a medição do desempenho de uma página e a apresentação de anúncios personalizados.

Embora a forma de apresentação das informações relativas ao uso de *cookies* seja distinta e possa variar muito de acordo com a página acessada, ao concordar com as condições estipuladas, o usuário estará sujeito a algum tipo de rastreamento das atividades que realiza na internet, seja pelo responsável pelo site ou por terceiros. Por isso, assim como pode ocorrer com o uso de tecnologias similares, a utilização de *cookies* sem as devidas salvaguardas técnicas e jurídicas pode gerar impactos negativos sobre os direitos e a privacidade de titulares de dados pessoais.

Um dos potenciais problemas relacionados ao uso de *cookies* é a falta de transparência, isto é, a não disponibilização de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a coleta e a realização do tratamento, o que pode inviabilizar ou restringir indevidamente o controle do titular sobre os seus dados pessoais. Os riscos à privacidade podem ser ampliados nas situações em que a falta de transparência está associada a práticas de coleta de quantidades massivas de informações pessoais para fins de identificar, rastrear e criar perfis comportamentais de usuários.

Considerando esses aspectos, que denotam tanto a importância quanto os riscos envolvidos na utilização de *cookies* no ambiente digital, o presente Guia apresenta um panorama geral sobre o tema, analisa os principais conceitos e categorias de *cookies* e examina as hipóteses legais aplicáveis e os requisitos a serem observados em caso de sua utilização.

Ademais, este Guia busca identificar práticas positivas e negativas na elaboração de políticas de *cookies*, mais precisamente quanto aos *banners* de *cookies* inseridos em sítios eletrônicos, e, ainda, instrui tal elaboração por meio de exemplos ilustrativos.

Não obstante o Guia ter como foco principal a coleta de dados pessoais por meio de *cookies* no acesso a páginas eletrônicas na internet, as orientações aqui apresentadas também são aplicáveis, de forma geral, para a coleta de dados pessoais mediante o uso de tecnologias similares de rastreamento, incluindo em dispositivos móveis (celulares e tablets, por exemplo), observadas as peculiaridades de cada contexto.

Ressalta-se que a observância do contido neste Guia não isenta os agentes de tratamento de observarem os demais preceitos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para fins de conformidade, regularidade e validade das

operações e da atividade de tratamento de dados pessoais, além de adotar as providências necessárias para resguardar os direitos dos titulares de dados.

Este Guia ficará aberto a comentários e contribuições de forma contínua, com o fim de atualizá-lo oportunamente, à medida que novas regulamentações e entendimentos forem estabelecidos, a critério da ANPD. As sugestões podem ser enviadas para a Ouvidoria da ANPD, por meio da Plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/).

Conceito e classificações

O que são cookies?

Cookies são arquivos instalados no dispositivo de um usuário que permitem a coleta de determinadas informações, inclusive de dados pessoais em algumas situações, visando ao atendimento de finalidades diversas[1]. Entre essas informações, muitas são essenciais para o funcionamento adequado e seguro de páginas eletrônicas e para viabilizar a oferta de serviços no ambiente digital. Assim, por exemplo, a utilização de *cookies* pode identificar um usuário antes de realizar uma transação *online* ou, ainda, "lembrar" opções feitas anteriormente, tais como o idioma utilizado, o tipo de produto preferido, as senhas e os logins utilizados em sítios eletrônicos, bem como produtos que foram adicionados ao carrinho para a realização de uma compra. Além disso, podem ser utilizados para outros fins, tais como a medição de audiência de uma página e a oferta de anúncios personalizados.

Destaca-se, ainda, que *cookies* permitem armazenar nos dispositivos dos usuários uma série de dados. As informações coletadas e armazenadas pelos *cookies* podem se referir diretamente a pessoas naturais ou, ainda, permitir indiretamente a sua identificação, mediante, por exemplo, a realização de inferências e o cruzamento com outras informações e, por vezes, por meio da formação de perfis comporta-

mentais. Neste último caso, é possível considerar o perfil comportamental como um dado pessoal, uma vez que associado a uma pessoa natural[2]. Nesse sentido, nas hipóteses acima mencionadas, as informações pessoais coletadas por meio de *cookies* podem ser consideradas dados pessoais, cujo tratamento é regulado pela LGPD.

Categorias de cookies

As categorias para definição dos *cookies* são diversas e podem partir de diferentes perspectivas. No presente Guia, serão apresentadas algumas das categorias mais comumente utilizadas, de forma não exaustiva, organizadas pelos tipos de *cookies* mais usuais. Importante considerar que um mesmo *cookie* pode ser incluído em mais de uma categoria.

Desse modo, a seguir são abordadas as categorias de cookies de acordo com: (i) a entidade responsável pela sua gestão; (ii) a necessidade; (iii) a finalidade; e (iv) o período de retenção das informações.

COOKIES DE ACORDO COM A ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA SUA GESTÃO

a. *Cookies* próprios ou primários: são os *cookies* definidos diretamente pelo site ou aplicação que o titular está visitando. Os *cookies* primários geralmente não podem ser usados para rastrear a atividade em outro site que não seja o site original em que foi colocado. Esses tipos de *cookies* podem incluir informações como credenciais de *login*, itens do carrinho de compras ou idioma preferido.

b. *Cookies* de terceiros: são *cookies* criados por um domínio diferente daquele que o titular está visitando. Decorrem de funcionalidades de outros domínios que são incorporadas a uma página eletrônica, a exemplo da exibição de anúncios.

COOKIES DE ACORDO COM A NECESSIDADE

c. *Cookies* necessários: são aqueles utilizados para que o site ou aplicação realize funções básicas e opere corretamente. Por isso, a coleta da informação é essencial para assegurar o funcionamento da página eletrônica ou para a adequada prestação do serviço. Dessa forma, as atividades abrangidas como estritamente necessárias incluem aquelas relacionadas à funcionalidade específica do serviço, ou seja, sem elas o usuário não seria capaz de realizar as principais atividades do site ou aplicação. Essa categoria se restringe ao essencial para prestar o serviço solicitado pelo titular, não contemplando finalidades não essenciais, que atendam a outros interesses do controlador.

d. *Cookies* não necessários: são *cookies* que não se enquadram na definição de *cookies* necessários e cuja desabilitação não impede o funcionamento do site ou aplicação ou a utilização dos serviços pelo usuário. Nesse sentido, *cookies* não necessários estão relacionados com funcionalidades não essenciais do serviço, da aplicação ou da página eletrônica. Exemplos de *cookies* não necessários incluem, entre outros, aqueles utilizados para rastrear comportamentos, medir o desempenho da página ou serviço, além de exibir anúncios ou outros conteúdos incorporados.

Vale ressaltar que a distinção entre *cookies* necessários e não necessários é especialmente relevante para a definição da hipótese legal que autoriza o uso de *cookies* e a coleta de dados pessoais, como o consentimento e o legítimo interesse, conforme abordado na próxima seção deste Guia.

COOKIES DE ACORDO COM A FINALIDADE

e. *Cookies* analíticos ou de desempenho: possibilitam coletar dados e informações sobre como os usuários utilizam o site, quais páginas

visitam com mais frequência naquele site, a ocorrência de erros ou informações sobre o próprio desempenho do site ou da aplicação.

f. *Cookies* de funcionalidade: são usados para fornecer os serviços básicos solicitados pelo usuário e possibilitam lembrar preferências do site ou aplicação, como nome de usuário, região ou idioma. Os *cookies* de funcionalidade podem incluir *cookies* próprios, de terceiros, persistentes ou de sessão.

g. *Cookies* de publicidade: são utilizados para coletar informações do titular com a finalidade de exibir anúncios. Mais especificamente, a partir da coleta de informações relativas aos hábitos de navegação do usuário, os *cookies* de publicidade permitem sua identificação, a construção de perfis e a exibição de anúncios personalizados de acordo com os seus interesses.

COOKIES DE ACORDO COM O PERÍODO DE RETENÇÃO DAS INFORMAÇÕES

h. *Cookies* de sessão ou temporários: são projetados para coletar e armazenar informações enquanto os titulares acessam um *site*. Costumam ser descartados após o encerramento da sessão, isto é, após o usuário fechar o navegador. São utilizados regularmente para armazenar informações que só são relevantes para a prestação de um serviço solicitado pelos usuários ou com uma finalidade específica temporária, como ocorre, em geral, com uma lista de produtos no carrinho de um *site* de compras.

i. *Cookies* persistentes: os dados coletados por meio desses *cookies* ficam armazenados e podem ser acessados e processados por um período definido pelo controlador, que pode variar de alguns minutos a vários anos. A esse respeito, deve ser avaliado no caso concreto se a utilização de *cookies* persistentes é necessária, uma vez que as amea-

ças à privacidade podem ser reduzidas com a utilização de *cookies* de sessão. Em qualquer caso, quando são utilizados *cookies* persistentes, é recomendável limitar sua duração no tempo, tanto quanto possível, considerando a finalidade para a qual foram coletados e serão tratados, conforme exposto mais adiante neste Guia.

Cookies e a LGPD

Aspectos gerais

Os *cookies* constituem um mecanismo útil para diversas finalidades, dentre as quais as de identificação de usuários, viabilização de pagamentos *online*, apresentação de anúncios e medição da eficácia de um serviço ou de uma página eletrônica. No entanto, o atendimento a essas finalidades somente será legítimo se respeitados os princípios, os direitos dos titulares e o regime de proteção de dados previstos na LGPD.

Dados pessoais coletados a partir de interações realizadas em um sítio na internet, em um aplicativo ou em um serviço digital, podem revelar diversos aspectos da personalidade e do comportamento de pessoas. Em tais contextos, essas pessoas são colocadas em uma posição de maior vulnerabilidade especialmente em face da assimetria de informação com relação a grandes provedores de aplicações de internet, que respondem pelo tratamento de uma quantidade massiva de dados pessoais ou quando os propósitos do tratamento não são apresentados de forma clara, precisa e facilmente acessível.

Antes mesmo da publicação da LGPD, o Marco Civil da Internet (MCI, Lei nº 12.965/2014) já havia reconhecido que, ao lado da liberdade de expressão, a garantia da privacidade e de proteção de dados pesso-

ais é condição essencial para o pleno exercício do direito de acesso à rede (arts. 3º, 7º e 8º). O MCI também estabeleceu forte proteção aos dados pessoais, ao prever que a sua guarda e disponibilização "*devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas*". Além disso, a disponibilização de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, mesmo quando associados a dados pessoais, para autoridades públicas ou para terceiros, somente pode ocorrer, em regra, mediante ordem judicial[3].

As disposições protetivas do MCI foram ampliadas pela LGPD, norma que dispôs sobre a proteção de dados pessoais de forma mais abrangente, incluindo a previsão de direitos para os titulares, de princípios norteadores para o tratamento de dados pessoais e de obrigações para os agentes de tratamento. Entre as principais disposições da LGPD aplicáveis à coleta de dados pessoais por meio de *cookies* ou de outras tecnologias de rastreamento *online*, merecem destaque as seguintes:

(i) **Princípios da finalidade, necessidade e adequação** (art. 6º, I, II e III): a coleta de dados pessoais mediante o uso de *cookies* deve ser limitada ao mínimo necessário para a realização de finalidades legítimas, explícitas e específicas, observada a impossibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Nesse sentido, a finalidade que justifica a utilização de determinada categoria de *cookies* deve ser específica e informada ao titular, e a coleta de dados deve ser compatível com tal finalidade. Por exemplo, caso o responsável pela página eletrônica informe ao titular que utiliza *cookies* apenas para a finalidade de medição de audiência, não poderá utilizar as informações coletadas para fins distintos e não compatíveis com essa finalidade, tais como para a formação de perfis e a exibição de anúncios. Da mesma forma, não poderá coletar outros dados pessoais não relacionados ou não compatíveis com essa finalidade. Por isso, não se admite a

indicação de finalidades genéricas, tal como ocorre com a solicitação de aceite de termos e condições gerais, sem a indicação das finalidades específicas de uso dos *cookies*. Além disso, o princípio da necessidade determina que o tratamento deve abranger apenas os *"dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados"*. Esse princípio desaconselha o próprio tratamento de dados pessoais quando a finalidade que se almeja pode ser atingida por outros meios menos gravosos ao titular de dados.

(ii) Princípios do livre acesso e da transparência (art. 6º, IV e VI): impõem ao agente de tratamento a obrigação de fornecer aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a forma do tratamento, o período de retenção e as finalidades específicas que justificam a coleta de seus dados por meio de *cookies*. Também é importante que sejam fornecidas informações sobre o eventual compartilhamento de dados com terceiros e sobre os direitos assegurados ao titular, entre outros aspectos indicados no art. 9º da LGPD.

> *Uma boa prática é a indicação ao titular sobre como gerenciar preferências de cookies em seu próprio navegador ou aparelho. Assim, por exemplo, pode ser objeto de explicação a forma pela qual os cookies podem ser excluídos ou, ainda, como desabilitar cookies de terceiros. Importante ressaltar que o gerenciamento de cookies pelo navegador possui uma função complementar, que não afasta a necessidade de disponibilização ao titular de um mecanismo direto e próprio para o gerenciamento de cookies e para o exercício de seus direitos, sempre acompanhado da indicação das informações correspondentes. Quanto à forma de apresentação, essas informações podem ser indicadas, por exemplo, em banners, apresentados após o acesso a uma página na internet; e, de forma mais detalhada, em políticas ou avisos de privacidade, que contenham informações sobre a política*

> *de cookies utilizada pelo agente de tratamento, conforme as recomendações apresentadas neste Guia.*

(iii) **Direitos do titular:** entre outros, são especialmente relevantes no contexto da utilização de *cookies*, o direito de acesso, de eliminação de dados, de revogação do consentimento e de oposição ao tratamento, sempre mediante procedimento gratuito e facilitado, conforme previsto no art. 18 da LGPD.

> *Para o atendimento a essa determinação legal, é recomendável a disponibilização ao titular de mecanismo para o "gerenciamento de cookies", por meio do qual seja possível, por exemplo, rever permissões anteriormente concedidas, como na hipótese de revogação de consentimento relacionado ao uso de cookies para fins de marketing, quando essa for a base legal utilizada.*

Importante enfatizar que, independentemente da tecnologia utilizada, não são compatíveis com a LGPD práticas que impliquem a coleta indiscriminada de dados pessoais – sem finalidade especificamente definida e clara para o titular – e o correspondente rastreamento ilimitado de seus titulares no ambiente digital. A violação aos direitos dos titulares ocorrerá, especialmente, quando a coleta não estiver amparada em uma hipótese legal apropriada e não forem disponibilizadas informações claras, precisas e facilmente acessíveis que confiram ao titular a efetiva possibilidade de compreender e de controlar o uso de seus dados pessoais.

(iv) **Término do tratamento e eliminação de dados pessoais:** a LGPD prevê que, como regra geral, os dados pessoais devem ser eliminados após o término do tratamento, o que pode ocorrer, por exemplo, quando a finalidade for alcançada ou a eliminação for legitimamente solicitada pelo titular. Dessa forma, o armazenamento de informações pessoais após o término do tratamento so-

mente é admitido em hipóteses excepcionais, tal como para fins de cumprimento de obrigação legal, entre outras hipóteses previstas no art. 16 da LGPD. Daí decorre que o período de retenção de *cookies* deve ser compatível com as finalidades do tratamento, limitando-se ao estritamente necessário para se alcançar essa finalidade. Por isso, períodos de retenção indeterminados, excessivos ou desproporcionais em relação às finalidades do tratamento não são compatíveis com a LGPD.

(v) **Hipóteses legais:** são as hipóteses em que a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais, conforme o disposto no art. 7º e no art. 11, este no caso de dados pessoais sensíveis. Assim, sempre que envolvido tratamento de dados pessoais, a utilização de *cookies* somente poderá ser admitida se identificada a hipótese legal aplicável pelo controlador e atendidos os requisitos específicos estipulados para esse fim na LGPD.

Hipóteses legais[4]

A seguir serão apresentadas duas hipóteses legais, o consentimento e o legitimo interesse, as mais usuais e relevantes para o contexto analisado. A indicação efetuada neste Guia não é exaustiva, uma vez que a coleta de dados pessoais por meio de cookies pode, eventualmente, se amparar em outras hipóteses legais, desde que atendidos os requisitos previstos na LGPD.

CONSENTIMENTO

De acordo com a LGPD, o consentimento deve ser livre, informado e inequívoco. O consentimento será livre quando o titular realmente tiver o poder de escolha sobre o tratamento de seus dados pessoais.

Ou seja, deve lhe ser assegurada a possibilidade efetiva de aceitar ou recusar a utilização de *cookies*, sem consequências negativas ou intervenções do controlador que possam vir a viciar ou a prejudicar a sua manifestação de vontade.

Em razão desse requisito legal, não é compatível com a LGPD a obtenção "forçada" do consentimento, isto é, de forma condicionada ao aceite integral das condições de uso de *cookies*, sem o fornecimento de opções efetivas ao titular. Deve-se ressalvar, no entanto, que a regularidade do consentimento deve ser verificada de acordo com o contexto e as peculiaridades de cada caso concreto, considerando-se, em particular, se é fornecida ao titular uma alternativa real e satisfatória.

O consentimento também deve ser informado, exigindo-se, para tanto, que sejam apresentadas ao titular todas as informações necessárias para uma avaliação e uma tomada de decisão consciente a respeito da autorização ou recusa para a utilização de *cookies*. Assim, como já mencionado, devem ser fornecidas aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a forma do tratamento, o período de retenção e as finalidades específicas que justificam a coleta de seus dados por meio de *cookies*, entre outras informações indicadas no art. 9º da LGPD.

É importante ressaltar que essas informações se vinculam à própria utilização do dado pessoal. Qualquer alteração das premissas adotadas para a obtenção do consentimento macula a hipótese legal adotada, exigindo novo consentimento pelo titular de dados, ou a utilização de outra hipótese legal, de acordo com as novas premissas estabelecidas e com todas as informações necessárias para tanto.

Além disso, o consentimento deve ser inequívoco, o que demanda a obtenção de uma manifestação de vontade clara e positiva do titular dos dados, não se admitindo a sua inferência ou a obtenção de forma

tácita ou a partir de uma omissão do titular. Por isso, dada a incompatibilidade com as disposições da LGPD, não é recomendável a utilização de *banners* de *cookies* com opções de autorização pré-selecionadas ou a adoção de mecanismos de consentimento tácito, como a pressuposição de que, ao continuar a navegação em uma página, o titular forneceria consentimento para o tratamento de seus dados pessoais.

No caso de coleta de dados sensíveis com base no consentimento do titular, é necessário que, adicionalmente, o consentimento seja obtido por forma específica e destacada, conforme preconiza o art. 11, I, da LGPD. Em relação à forma destacada, recomenda-se que a autorização para tratamento de dados sensíveis conste separadamente do texto principal ou, ainda, que se usem recursos para evidenciá-lo, de modo a indicar quais dados sensíveis serão coletados e para qual finalidade específica serão utilizados pelo agente de tratamento.

Em qualquer caso, deve ser disponibilizado ao titular um procedimento simplificado e gratuito para revogar o consentimento fornecido para a utilização de *cookies*, de forma similar ao procedimento utilizado para obtê-lo. Nesse sentido, o art. 8º, § 5º, da LGPD, estabelece que "*o consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado*". O ato de revogação é unilateral e deverá ser atendido sempre que requisitado pelo titular.

Importante observar que compete ao controlador a responsabilidade de comprovar que o consentimento foi obtido com respeito a todos os parâmetros estabelecidos pela LGPD. Dessa forma, é uma boa prática o registro e a documentação de todos os requisitos necessários para a comprovação de que o consentimento não possui vícios e contou com todas as informações necessárias.

Diante do que estabelecem esses requisitos legais, pode-se afirmar que não é apropriado utilizar a hipótese legal do consentimento nas hipóteses de *cookies* estritamente necessários. Isso porque, nestes casos, a coleta da informação é essencial para assegurar o funcionamento da página eletrônica ou para a adequada prestação do serviço, de modo que não há condições efetivas para uma manifestação livre do titular ou, ainda, para que se assegure a este a real possibilidade de escolher entre aceitar ou recusar o tratamento de seus dados pessoais.

De forma similar, o consentimento não será a hipótese legal apropriada se o tratamento for estritamente necessário para o cumprimento de obrigações e atribuições legais, notadamente quando demonstrada a existência de um vínculo claro e direto entre a coleta de dados por meio de *cookies* e o exercício de prerrogativas estatais típicas por entidades e órgãos públicos[12]. Em qualquer hipótese, devem ser fornecidas aos titulares as informações pertinentes, em conformidade com os princípios da transparência e do livre acesso, além de assegurado o exercício de seus direitos e observadas as disposições do art. 23 da LGPD.

Assim, embora inexista hierarquia ou preferência entre as hipóteses legais previstas na LGPD, o recurso ao consentimento será mais apropriado quando a coleta de informações for realizada por *cookies* não necessários. Nessas situações, a coleta da informação não é essencial para a adequada prestação do serviço ou para assegurar o funcionamento da página eletrônica. De fato, como visto anteriormente, cookies não necessários estão relacionados com funcionalidades não essenciais do serviço ou da página eletrônica, a exemplo da exibição de anúncios ou da formação de perfis comportamentais. Nesses casos, torna-se possível fornecer ao usuário uma opção genuína entre aceitar ou recusar a instalação de *cookies* para uma ou mais dessas finalidades, pressuposto central para a utilização da hipótese legal do consentimento.

EXEMPLO 1

Coleta de cookies em página eletrônica de supermercado

Ao acessar a página eletrônica de um supermercado para efetuar a compra de um produto, o usuário é direcionado a um banner no qual consta a informação de que "esta página utiliza cookies para melhorar a sua experiência, obter estatísticas de uso e encaminhar anúncios relevantes para você". Nenhuma informação adicional é apresentada e a única opção fornecida é expressa na caixa "Estou de acordo".

Análise · Os *cookies* cuja coleta é informada pelo banner disponível na página do supermercado se caracterizam como cookies não necessários, tendo o agente de tratamento optado por solicitar o consentimento do titular. Entretanto, o fornecimento de uma opção única para o titular dos dados, sem a possibilidade de recusar a utilização de *cookies* não necessários, contraria a exigência de que o consentimento seja livre. Além disso, a ausência de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre, entre outros aspectos, as finalidades específicas do tratamento e o período de retenção dos dados, viola a exigência legal de que o consentimento deve ser informado. Por fim, a não disponibilização de mecanismo simplificado e gratuito para a revogação do consentimento, a qualquer momento, pelo titular, também é uma prática incompatível com a LGPD.

EXEMPLO 2

Adequação da página eletrônica de uma escola à LGPD

Uma escola recebeu uma reclamação de uma associação de pais sobre a falta de transparência da coleta de dados pessoais por meio de cookies em sua página eletrônica. Ao usuário que acessava a página era apresentado apenas um banner com o botão "entendi", acompanhado da informação "ao clicar em 'entendi', você concorda com o armazenamen-

to de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site e os nossos serviços, assim como para auxiliar nossos esforços de marketing". Após a realização de estudos e a identificação de boas práticas, que contou com a colaboração do encarregado e o apoio da alta administração, a nova versão da página da escola apresenta ao usuário um banner com a seguinte informação: "esta página utiliza cookies necessários para o seu funcionamento. Se você fornecer o seu consentimento, também utilizaremos cookies para coletar dados que irão permitir a exibição de anúncios personalizados." Além dessas informações, o banner passou a contar com três opções, todas com o mesmo formato e destaque: "aceitar todos os cookies"; "rejeitar todos os cookies"; e "gerenciar cookies". Ao clicar nesta última opção, o usuário é direcionado para um banner de segundo nível, do qual constam informações mais detalhadas sobre o uso de cookies, tais como as suas respectivas finalidades específicas e o período de retenção. Os cookies baseados no consentimento estão desativados por padrão, com a possibilidade de o usuário marcar as opções que entender adequadas para a coleta de seus dados pessoais.

Análise · A possibilidade de aceitar ou recusar a utilização de *cookies* não necessários, de modo independente dos *cookies* necessários, permite que o consentimento seja livre. Além disso, os novos *banners* passaram a trazer informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre, entre outros aspectos, as finalidades específicas do tratamento e o período de retenção dos dados, em conformidade com a exigência legal de que o consentimento deve ser informado. Adicionalmente, em conformidade com o disposto na LGPD, os *cookies* baseados no consentimento estão desativados por padrão. Por fim, faltou apenas a disponibilização de mecanismo simplificado e gratuito para a revogação do consentimento, a qualquer momento, pelo titular, para que a página estivesse compatível com a LGPD.

LEGÍTIMO INTERESSE

A hipótese legal do legítimo interesse autoriza o tratamento de dados pessoais de natureza não sensível quando necessário ao atendimento de interesses legítimos do controlador ou de terceiros, *"exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais"* (art. 7º, IX).

O interesse do controlador será considerado legítimo quando for compatível com o ordenamento jurídico e não contrariar as disposições da lei. Além disso, o controlador deverá avaliar, em momento anterior à realização de qualquer operação baseada em legítimo interesse, se, no caso, prevalecem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais e, portanto, impeçam a realização do tratamento. Como em qualquer operação de tratamento de dados, é importante também comprovar a adoção de medidas técnicas e administrativas capazes de salvaguardar a operação e os dados utilizados, garantindo a segurança do tratamento e a transparência para os titulares.

A avaliação a ser realizada pelo controlador acerca das legítimas expectativas do titular de dados deve considerar o respeito aos seus direitos e liberdades individuais. Para ser adequado o tratamento, o controlador deve se certificar de que a utilização pretendida, além de não ferir direitos e liberdades, poderia ser razoavelmente prevista pelo titular de dados, isto é, que seria possível ao titular supor que aquela utilização poderia ocorrer com seus dados pessoais a partir das informações prestadas pelo controlador no momento da coleta do dado pessoal. Além disso, deve-se considerar que, conforme o art. 18, § 2º, o titular tem o direito de se opor ao tratamento realizado com base no legítimo interesse, em caso de descumprimento dos requisitos previstos na LGPD.

De forma geral, o legítimo interesse poderá ser a hipótese legal apropriada nos casos de utilização de *cookies* estritamente necessários, isto é, aqueles que são essenciais para a adequada prestação do serviço ou para o funcionamento da página eletrônica, o que pode ser entendido como uma forma de apoio e promoção de atividades do controlador e de prestação de serviços que beneficiem o titular (art. 10, I e II, LGPD). A análise, no entanto, deve considerar as peculiaridades de cada situação concreta e avaliar se, no caso, não prevalecem os direitos e interesses dos titulares, observados os demais requisitos legais aplicáveis.

No caso do setor público, a hipótese legal do legítimo interesse poderá amparar a coleta dos dados pessoais por meio de *cookies*, salvo, conforme orientação já firmada pela ANPD, em caso de vínculo claro e direto entre o tratamento e o exercício de prerrogativas estatais típicas, que decorrem do cumprimento de obrigações e atribuições legais[61].Em qualquer hipótese, devem ser fornecidas aos titulares as informações pertinentes, em conformidade com os princípios da transparência e do livre acesso, além de assegurado o exercício de seus direitos e observadas as disposições do art. 23 da LGPD.

A utilização de *cookies* para fins de medição de audiência (*cookies* analíticos ou de medição) pode ser amparada na hipótese legal do legítimo interesse em determinados contextos, observados, em qualquer hipótese, os requisitos previstos na LGPD. Em particular, é razoável supor que a medição de audiência constituirá um interesse legítimo do controlador, bem como que os riscos à privacidade de titulares serão de menor monta quando o tratamento se limitar à finalidade específica de identificação de padrões e tendências, com base em dados agregados e sem a combinação com outros mecanismos de rastreamento ou sem a formação de perfis de usuários.

Por outro lado, é possível afirmar que o legítimo interesse dificilmente será a hipótese legal mais apropriada nas hipóteses em que os dados coletados por meio de cookies são utilizados para fins de publicidade. É o que se verifica, em especial, se a coleta é efetuada por meio de *cookies* de terceiros e quando associada a práticas que podem implicar maior risco à privacidade e aos direitos fundamentais dos titulares, como as de formação de perfis comportamentais, análise e previsão de preferências e comportamentos ou, ainda, rastreamento do usuário por páginas eletrônicas distintas.

Em tais contextos, o teste de balanceamento previsto na LGPD conduzirá, em geral, à conclusão de que devem prevalecer direitos e liberdades fundamentais dos titulares sobre os interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Assim, o consentimento pode ser considerado uma hipótese legal mais apropriada para o uso de cookies de publicidade, observados os requisitos legais aplicáveis e as circunstâncias do caso concreto. Essa conclusão é reforçada ao se considerar que os cookies de publicidade são classificados como não necessários e que é de suma importância respeitar as legítimas expectativas dos titulares, conferindo-lhes maior controle sobre o uso de seus dados pessoais no ambiente digital.

EXEMPLO 3

Legítimo interesse na utilização de cookies necessários.

Uma livraria disponibiliza em sua página eletrônica a venda online de livros. Para tanto, utiliza cookies que garantem a adequada autenticação do usuário, a realização de pagamento e o armazenamento de informações referentes aos itens inseridos no carrinho de compras. No banner de cookies, a livraria informa a coleta exclusivamente para essas finalidades específicas; essas informações também estão na política de cookies.

Análise · Nesse caso, os cookies utilizados são estritamente necessários para o funcionamento da página, uma vez que relacionados a elementos essenciais do serviço de venda *online* de livros. O interesse do controlador pode ser considerado legítimo, na medida em que suporta e promove suas atividades, viabilizando a prestação de serviços que beneficiam o titular. Além disso, a utilização dos dados pessoais exclusivamente para essas finalidades específicas, conforme informado no *banner* e na política de *cookies* do controlador, atende às expectativas legítimas dos titulares.

EXEMPLO 4

Utilização de cookies para medição de audiência.

Um centro cultural de um município, constituído sob a forma de autarquia, resolveu adotar cookies em sua página eletrônica, com a finalidade específica de obter estatísticas de visitação e de desempenho de determinadas funcionalidades do site. Após avaliação interna, a autarquia concluiu que a coleta de dados por meio dos cookies em questão poderia ser realizada com base em seu legítimo interesse, tendo em vista a limitação da coleta ao estritamente necessário para a finalidade específica e exclusiva de medir a audiência da página eletrônica, conforme descrito acima. Os dados coletados são, ainda, agregados, visando à produção de estatísticas anônimas. Essas informações não são compartilhadas com terceiros e nem cruzadas com outros bancos de dados visando alcançar outras finalidades. A explicação sobre a utilização desses cookies, as suas finalidades e respectivos períodos de retenção, além da possibilidade de oposição ao tratamento, é apresentada ao titular no banner e na política de cookies.

Análise · O tratamento dos dados com base no legítimo interesse da autarquia é compatível com a LGPD, pois, na hipótese, a coleta dos dados não é legalmente compulsória e não há vínculo

claro e direto entre a sua finalidade específica e o exercício de uma prerrogativa estatal típica. Por isso, é possível realizar uma ponderação entre os interesses da autarquia e os direitos e as expectativas legítimas dos titulares. O fato de os dados coletados serem destinados exclusivamente para produzir estatísticas de visitação, não serem compartilhados com terceiros ou combinados com outras informações, além de serem apresentadas informações em conformidade com o princípio da transparência, são elementos que reforçam a legitimidade do interesse da autarquia em realizar o tratamento e que indicam ser reduzido o impacto sobre os direitos dos titulares.

Políticas de cookies

Para atender ao princípio da transparência e auxiliar o titular a compreender o tratamento dos dados pessoais coletados por meio de *cookies*, recomenda-se a elaboração de uma Política de *Cookies* ou documento equivalente – isto é, uma declaração pública que disponibilize informações aos usuários de um site ou aplicativo. Em conformidade com os princípios do livre acesso e da transparência, a Política de *Cookies* deve apresentar informações sobre as finalidades específicas que justificam a coleta de dados pessoais por meio de cookies, o período de retenção e se há compartilhamento com terceiros, entre outros aspectos indicados no art. 9º da LGPD.

É importante diferenciar Política de *Cookies* de *Banner* de *Cookies*. O *Banner* de *Cookies* é um recurso visual usado no *design* de aplicativos ou *sites* na internet, que utiliza barras de leitura destacadas para informar ao titular de dados, de forma resumida, simples e direta, sobre a utilização de *cookies* naquele ambiente. Além disso, o *banner* fornece ferramentas para que o usuário possa ter maior controle sobre o tratamento, como, por exemplo, permitindo que ele consinta ou não com determinados tipos de *cookies*. Existem diversas maneiras de se elaborar um *Banner* de *Cookies*, e as boas práticas, como, por exemplo, as técnicas de *design* conhecidas como *User Experience*, ou UX, em geral se alinham com os princípios e as obrigações da LGPD para o tratamento de dados pessoais.

Por sua vez, a Política de *Cookies* costuma ser disponibilizada em uma página específica, que contém informações mais detalhadas sobre o assunto, podendo ser acessada, em geral, por meio de *link* apresentado no *banner*. Ela também pode estar integrada, de forma destacada e de fácil acesso, ao Aviso de Privacidade (ou "Política de Privacidade") – a declaração pública do agente de tratamento sobre o tratamento de dados pessoais de uma forma geral. Em alguns casos, o agente de tratamento prefere trazer a sua Política de *Cookies* diluída no *banner* de *cookies*, ou seja, o conjunto de informações sobre o uso de *cookies* aparece nas diversas camadas do *banner*.

Desde que as informações essenciais sejam apresentadas ao titular, todas essas opções são legítimas, de modo que a Política de *Cookies* pode ser apresentada: (i) como uma seção específica do Aviso de Privacidade; (ii) em um local específico e separado; ou (iii) no próprio *banner* de *cookies*. Ou seja, independentemente do mecanismo adotado, o importante é que sejam disponibilizadas informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o uso de *cookies* e a coleta de dados pessoais quando o titular acessa uma determinada página eletrônica, serviço ou aplicativo, em conformidade com os princípios da transparência e do livre acesso e com o art. 9º da LGPD.

Banners de cookies

Os *banners* de *cookies* são mecanismos difundidos no ambiente digital, desenvolvidos como uma forma de materialização dos princípios previstos na LGPD, em especial os da transparência e do livre acesso. Ao apresentar informações essenciais sobre o uso de cookies de maneira resumida e simplificada, os *banners* contribuem para o processo de tomada de decisão consciente pelo titular, além de fortalecer o controle sobre seus dados pessoais e o respeito às suas legítimas expectativas. Assim, o *banner* serve como uma ferramenta para trazer transparência e aderência aos princípios de proteção de dados pessoais.

Nesse sentido, no presente tópico serão apresentadas orientações não exaustivas, consideradas como boas práticas, a fim de auxiliar os agentes de tratamento na elaboração de *banners* de *cookies* de forma compatível com as disposições da LGPD.

O que observar na elaboração

BANNERS DE PRIMEIRO NÍVEL

- Disponibilizar botão que permita rejeitar todos os *cookies* não necessários, de fácil visualização, nos *banners* de primeiro e segundo nível.



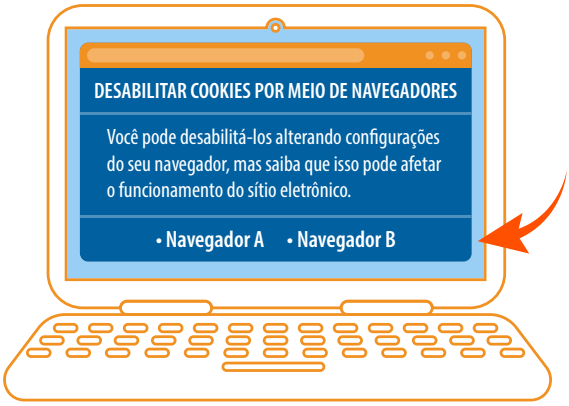
- Fornecer um *link* de fácil acesso para que o titular possa exercer os seus direitos, que pode incluir, por exemplo, saber mais detalhes sobre como seus dados são utilizados e sobre o período de retenção, além de solicitar a eliminação dos dados, opor-se ao tratamento ou revogar o consentimento.

BANNERS DE SEGUNDO NÍVEL

- Classificar os *cookies* em categorias no *banner* de segundo nível;
- Descrever as categorias de *cookies* de acordo com seus usos e finalidades;
- Apresentar descrição e informações simples, claras e precisas quanto a essas finalidades;
- Permitir a obtenção do consentimento para cada finalidade específica, de acordo com as categorias identificadas no *banner* de segundo nível, quando couber;
- Desativar cookies baseados no consentimento por padrão.



- Disponibilizar informações sobre como realizar o bloqueio de *cookies* pelas configurações do navegador. Caso o *cookie* ou rastreador não possa ser desabilitado por meio do navegador, o titular deverá ser informado a respeito.



O que evitar na elaboração de banners de cookies

A seguir são descritas práticas desaconselhadas quando da elaboração de banners de cookies em sítios eletrônicos.

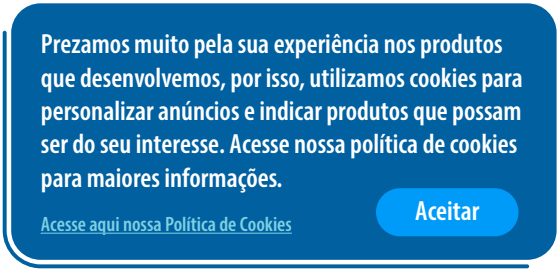
- Utilizar um único botão no *banner* de primeiro nível, sem opção de gerenciamento no caso de utilizar a hipótese legal do consentimento ("concordo", "aceito", "ciente" etc.);
- Dificultar a visualização ou compreensão dos botões de rejeitar *cookies* ou de configurar *cookies*, e conferir maior destaque apenas ao botão de aceite;
- Impossibilitar ou dificultar a rejeição de todos os *cookies* não necessários;
- Apresentar *cookies* não necessários ativados por padrão, exigindo a desativação manual pelo titular;
- Não disponibilizar *banner* de segundo nível;
- Não disponibilizar informações e mecanismo direto, simplificado e próprio para o exercício dos direitos de revogação do consentimento e de oposição ao tratamento pelo titular (além das configurações de bloqueio do navegador);
- Dificultar o gerenciamento de *cookies* (exemplo: não disponibilizar opções específicas de gerenciamento para *cookies* que possuem finalidades distintas);
- Apresentar informações sobre a política de *cookies* apenas em idioma estrangeiro;
- Apresentar lista de *cookies* demasiadamente granularizada, gerando uma quantidade excessiva de informações, o que dificulta a compreensão e pode levar ao efeito de fadiga, não permitindo a manifestação de vontade clara e positiva do titular;
- Ao utilizar o consentimento como hipótese legal, vincular a sua obtenção ao aceite integral das condições de uso de *cookies*, sem o fornecimento de opções efetivas ao titular.

Exemplos de banners de cookies

EXEMPLO 5

Banner de Cookies (primeiro nível)

A empresa Delta, a fim de garantir conformidade das práticas de cookies à legislação de proteção de dados, atualizou seu sítio eletrônico, inserindo na página inicial o seguinte banner de cookies:

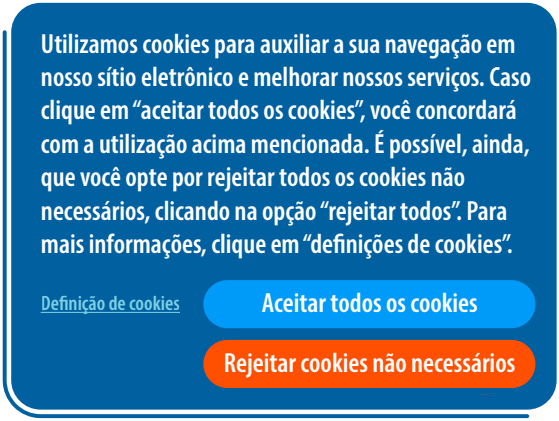


Análise · No exemplo, o *banner* informa em linhas gerais as finalidades do tratamento de *cookies* e oferece um link para acesso à Política de *cookies* do *site*. Contudo, só é possível visualizar um botão "Aceitar", de modo que não é possível garantir a manifestação clara do consentimento para o tratamento, nos termos da LGPD. Desse modo, o *banner* deve ser ajustado, mediante a inclusão de opção para: (i) rejeição de *cookies* não necessários; e (ii) gerenciamento de *cookies* por meio de *banner* de segundo nível.

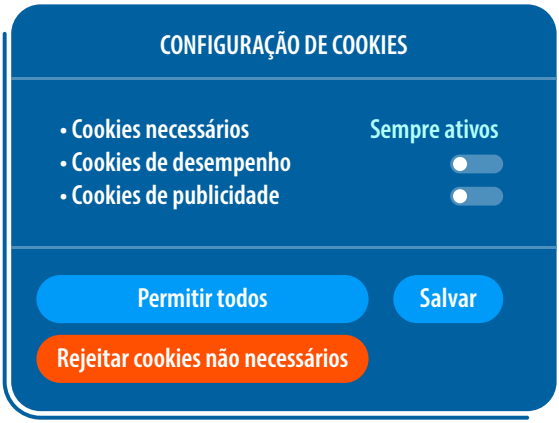
EXEMPLO 6

Banners de Cookies (primeiro e segundo nível)

A empresa Alpha, ao atualizar seu sítio eletrônico, inseriu banner de cookies contendo o seguinte texto:



Um cliente de Alpha acessa o sítio eletrônico e se depara com tal banner em primeiro nível. Uma vez que não pretende aceitar ou recusar todos os cookies, o cliente clica na opção "definições de cookies", que o encaminha para um banner de segundo nível, no qual é possível visualizar informações mais detalhadas.



Neste segundo banner, os cookies são agrupados em categorias: necessários, de desempenho e de publicidade. Com exceção da primeira

categoria, as demais estão desativadas por padrão. É possível obter o consentimento específico de cada categoria, com exceção da primeira, que são cookies necessários para a navegação. Além disso, o botão de "Rejeitar cookies não necessários" permanece em destaque.

Análise · No exemplo acima, de forma compatível com as disposições da LGPD sobre consentimento, o *banner* de *cookies* em primeiro nível, diferentemente do EXEMPLO 5, apresenta botão para que sejam rejeitados todos os *cookies*. Também em conformidade com a LGPD, observa-se um *banner* de segundo nível que permite a obtenção do consentimento específico de acordo com as categorias identificadas. Outro ponto positivo refere-se à desativação por padrão dos *cookies* não necessários, assegurando-se a obtenção de uma manifestação positiva do titular dos dados pessoais.

EXEMPLO 7

Política de Cookies junto à Política de Privacidade

José, contador, ao criar o sítio eletrônico de seu escritório de contabilidade, optou por disponibilizar a Política de Cookies junto à Política de Privacidade.

Análise · Esta prática pode ser legitimamente adotada, preferencialmente conferindo-se acesso facilitado à seção sobre a política de *cookies*. Por exemplo, o acesso pode ser facilitado por meio de uma guia, barra lateral ou sumário no início da Política de Privacidade. Todavia, disponibilizar informações sobre *cookies* somente por meio da Política de Privacidade pode não ser suficiente, pois o titular de dados nem sempre irá consultar a página da Política de Privacidade de um *site*. Assim, recomenda-se que sejam configurados recursos para que o titular possa identificar tais informações separadamente assim que acessar a plataforma, como, por exemplo, pela utilização de *banner* de segundo nível.

Considerações finais

O presente Guia foi elaborado a fim de orientar os agentes de tratamento quanto às boas práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais decorrente da coleta de *cookies*. Para tanto, buscou-se trazer o conceito de *cookies*, algumas categorias em que podem ser classificados, e as suas finalidades. Além disso, foram elencadas as principais disposições da LGPD aplicáveis à coleta de dados pessoais por meio de *cookies*. Foram apresentadas, ainda, orientações quanto à elaboração de Políticas de *Cookies* e de *banners* de *cookies*, por meio de exemplos ilustrativos.

Por fim, ressalta-se que este documento poderá adequar-se a futuras regulamentações sobre os temas aqui elencados e deve ser entendido como um guia de boas práticas, que poderá ser atualizado e aperfeiçoado sempre que necessário.

Notas

Conceito e classificações ▸ p. 8–12

[1] Outras possíveis definições podem ser consultadas em: HOOFNAGLE, et al. *Behavioral Advertising: The Offer You Cannot Refuse*. Harvard Law & Policy Review, vol.6, n. 273, 2012. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2137601 e KRISTOL, David.M. HTTP *Cookies: Standards, Privacy, and Politics*. ACM Transactions on Internet Technology, Vol. 1, No. 2, 2001. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/502152.502153. ▸ p.8

[2] Conforme o art. 12, § 2º, da LGPD: "Art. 12. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada". ▸ p.9

Cookies e a LGPD ▸ p. 13–27

[3] A matéria está regulada no art. 10 do MCI, que ressalva a possibilidade de acesso a dados cadastrais por autoridades administrativas competentes. Em sentido similar, os incisos II e III do art. 7º asseguram a inviolabilidade e o sigilo do fluxo das comunicações privadas pela internet, incluindo das comunicações privadas armazenadas, "salvo por ordem judicial". ▸ p.14

[4] As orientações aqui apresentadas sobre as bases legais do consentimento e do legítimo interesse seguem, com adaptações, o exposto no *Guia Orientativo – Aplicação da LGPD por agentes de tratamento no contexto eleitoral*, p. 21–25; e 27–29. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia_lgpd_final.pdf. ▸ p.17

[5] Vale ressaltar que "o consentimento poderá eventualmente ser admitido como base legal para o tratamento de dados pessoais pelo Poder Público. Para tanto, a utilização dos dados não deve ser compulsória e a atuação estatal não deve, em regra, basear-se no exercício de prerrogativas estatais típicas, que decorrem do cumprimento de obrigações e atribuições legais". *Guia Orientativo – Tratamento de dados pessoais pelo Poder Público*, jan. 2022, p. 7. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf. ▸ p.20

[6] Vale ressaltar que "o legítimo interesse poderá eventualmente ser admitido como base legal para o tratamento de dados pessoais pelo Poder Público. Para tanto, a uti-

lização dos dados não deve ser compulsória ou, ainda, a atuação estatal não deve se basear no exercício de prerrogativas estatais típicas, que decorrem do cumprimento de obrigações e atribuições legais. Nesse contexto, torna-se efetivamente possível realizar uma ponderação entre, de um lado, os interesses legítimos do controlador ou de terceiro e, de outro, as expectativas legítimas e os direitos dos titulares." *Guia Orientativo – Tratamento de dados pessoais pelo Poder Público*, jan. 2022, p. 8. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf. ▸ p.24

ANPD

Autoridade Nacional de Proteção de Dados

www.anpd.gov.br



@anpdgov